

1500600-30.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... já conhecido pela constante prática do tráfico de drogas, visualizaram o acusado e o adolescente em uma esquina. Ao avistarem a aproximação da viatura, eles passaram a caminhar em direções opostas. O menor, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o narcotráfico, dispensou algo no chão, o que lhes despertou suspeita. Efetuaram então a abordagem de ambos e, em busca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1500600-30.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500600-30.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR APARECIDO BATISTA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

VÍTOR APARECIDO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 13:45 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Avenida José dos Santos Seves, nº 1019, Jardim Roberto Selmi Dei, nesta cidade e comarca, agindo de comum acordo e com identidade de propósitos com o adolescente Victor Gabriel da Silva Souza (na época com 17 anos de idade), trazia consigo, para fins de tráfico, 7 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,46 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apresentada defesa preliminar (fls. 131/135), a denúncia foi recebida (fl. 136). O

réu foi citado (fl. 164).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação e uma pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final (fls. 167/170).

Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que a Nobre Defensora postulou a sua absolvição ou, em caso contrário, o reconhecimento do privilégio (fls. 167/170).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e dos laudos de constatação provisória (fls. 31/34) e definitiva de entorpecentes (fls. 110/112), com resultados positivos para cocaína.

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado manteve-se em silêncio (fl. 18).

Em juízo, afirmou que, na data dos fatos, conversava com 2 amigos no local em questão quando avistou o menor Victor do outro lado da avenida e, em seguida, todos foram abordados por policiais militares. Trazia consigo a quantia em dinheiro de R\$ 160,00 em notas trocadas, oriunda do seu trabalho em uma loja, e um celular, que foram apreendidos. Em poder do menor foi encontrada certa quantia em dinheiro. A droga estava guardada em uma sacolinha que ele dispensara antes da abordagem. Negou que estivesse em companhia do adolescente e tampouco soube dizer se ele tinha envolvimento com o narcotráfico, pois não o conhecia. Os amigos com quem conversava na ocasião eram menores e, por essa razão, acredita que não tenham sido apreendidos pelos policiais. O local dos fatos é situado a 2 quarteirões de sua casa. Negou o envolvimento com o uso ou a venda de drogas. Na época do ocorrido trabalhava como vendedor em uma loja e atualmente trabalha em uma pastelaria. Esclareceu ainda ter ido, pouco antes da abordagem, a um bar para trocar seu dinheiro e assim poder pagar a corrida de Uber, pois iria a uma festa. As notas eram de 2, 5, 10 e 20 reais (cf. gravação audiovisual de fls. 167/170).

Ocorre, porém, que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu em juízo, o acervo probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Durante e Neiva relataram que, na data mencionada, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela constante prática do tráfico de drogas, visualizaram o acusado e o adolescente em uma esquina. Ao avistarem a aproximação da viatura, eles passaram a caminhar em direções opostas. O menor, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o narcotráfico, dispensou algo no chão, o que lhes despertou suspeita. Efetuaram então a abordagem de ambos e, em busca pessoal, foi encontrada com o réu a quantia de R\$ 160,00 em notas miúdas, além de um celular. Em poder do menor foram localizados R\$ 9,95 em notas e moedas. A sacolinha que o adolescente dispensara continha 7 eppendorfs de cocaína, sendo 5 de cor amarela e 2 de cor preta. Indagado, o acusado inicialmente negou a prática do tráfico de drogas, mas depois passou a afirmar que passava pelo local para recolher o dinheiro que estava em poder do adolescente, que era produto da venda de drogas. Já o menor de pronto

assumiu a comercialização do entorpecente no local, informando que vendia cada pino de cocaína ao preço unitário de R\$ 10,00, e revelou que, antes de ser abordado, entregara parte do dinheiro das vendas ao réu. No momento da abordagem estavam no local apenas o acusado e o adolescente (cf. gravação audiovisual de fls. 167/170).

Neiva ainda acresceu que o local dos fatos é conhecido como “lojinha da 40” ou “biqueira da 40”, devido ao fato de o tráfico de entorpecentes ser bem intenso naquele ponto da cidade.

Por fim, a testemunha de defesa Sílvia, vizinha do acusado, não presenciou os fatos e se limitou a abonar a sua vida pregressa. Nunca soube do suposto envolvimento do réu com o narcotráfico e desconhecia eventual amizade entre ele e o adolescente. Na época dos fatos o imputado trabalhava fazendo bicos com entregas e como empacotador e atualmente o faz em uma pastelaria (cf. gravação audiovisual de fls. 167/170).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Ressalte-se, desde logo, que, diversamente do sustentado pela Defesa Técnica, nada há nos autos que possa diminuir o valor probante dos depoimentos dos policiais militares inquiridos no curso do feito.

Afinal, está pacificado na jurisprudência que a condição de policial - seja militar ou civil, estadual ou federal -, por si só, não invalida o seu testemunho prestado em juízo, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Confira-se:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - Habeas Corpus nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello).

No contexto dos autos, a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida não apenas pela palavra do menor em solo policial, mas sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico apreendido (7 pinos do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido total de 2,46 gramas - cf. auto de fls. 14/15 e laudos de fls. 31/34 e 110/112 -, já separados individualmente para a revenda e entrega a terceiros, cf. fotografia de fl. 16), bem como pela apreensão de um celular em poder do réu, certamente utilizado como instrumento do crime.

Cumpra ainda destacar que houve a apreensão, no mesmo cenário fático, em poder do acusado e do adolescente infrator, de quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 169,95 no total), certamente relacionada à prática ilícita em questão (cf. auto de fls. 14/15 e guia de fl. 97).

Note-se, a propósito, que o imputado não apresentou nenhuma prova cabal da eventual origem lícita do referido numerário, mas apenas a alegação vaga e genérica de que era proveniente de seu trabalho como vendedor em uma loja, o que reforça a conclusão de que era mesmo oriundo da nefasta mercancia.

Além disso, no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em solo judicial e dos documentos de fls. 100/109, que apontam a existência de diversas denúncias anônimas alusivas a tal prática ilícita naquelas áreas.

Ressalte-se ainda que, ao ser abordado, o menor infrator admitiu aos castrenses a dedicação ao comércio espúrio no local dos fatos e chegou a apontar o preço unitário de cada pino de cocaína que ali vendia (dez reais). O jovem revelou também que, pouco antes da abordagem policial, entregara ao acusado parte do dinheiro, que era produto das vendas, permitindo inferir-se que ambos agiam de comum acordo e com identidade de propósitos na empreitada criminosa.

Tais aspectos, examinados em seu conjunto, confirmam a ocorrência na espécie do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que os agentes transportem, tragam consigo, guardem ou mantenham em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Desse modo, todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era pertencente ao réu e a seu comparsa e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros – ainda que de forma gratuita –, não sendo unicamente para o uso próprio de ambos (até porque o réu declarou em juízo não ser usuário de drogas).

E, ainda que assim não fosse, é consabido que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples 'guarda temporária' da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Convém ainda registrar, por fim, a reforçar a maior reprovabilidade da conduta ilícita do réu, que sua ação envolveu diretamente o então adolescente Victor Gabriel da Silva Souza, com 17 anos de idade ao tempo dos fatos (cf. Ficha de Identificação Civil acostada à fl. 23), o qual também foi surpreendido, como visto, na data e no local dos fatos, a atrair a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não obstante a presença, na segunda fase da dosimetria penal, da atenuante genérica da menoridade do réu na data do fato (art. 65, inciso I, do CP), as penas não podem ser reduzidas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Colendo STJ).

Outrossim, embora não haja dúvida de que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual, ausente o nexo causal, deve ser afastada a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Confira-se:

"Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações" (TJSP - Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Na derradeira etapa do procedimento trifásico, presente a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas), elevo as penas em 1/6 (um sexto), alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida (2,46 gramas de cocaína), as penas devem ser reduzidas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), no grau máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo assim o total de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso mínimo.

Torno-as, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Insta consignar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentara o entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possuía entendimento sumulado em sentido diametralmente oposto ao acima descrito, cancelou o Enunciado 512 de sua Súmula, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso.

E, por fim, recentemente a legislação em vigor veio a contemplar referido posicionamento, consoante se infere do teor do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, acrescido pela Lei nº 13.964/19, que dispõe, in verbis:

"Art. 112 (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Desse modo, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu será cumprida

inicialmente em regime prisional aberto, tendo em vista o quantum da reprimenda e a ausência de circunstâncias capazes de justificar a imposição de regime mais gravoso.

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, faz jus o imputado à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva, e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu VÍTOR APARECIDO BATISTA à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do objeto e do numerário apreendidos (cf. auto de fls. 14/15 e guia de fl. 97), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA